

CHRISTOPH FUCHS

lwn

NATASSIA DIAMOND BINTI MOHD JHOMI

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato Haji Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Ahli Panel)

10 Mac 2020 / 15 Rejab 1441H

Kes Semakan No. 10000-003-0098-2019

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Tuan Mohd Hafizal bin Haji Parcho daripada Tetuan Hafizal Parcho & Associates.

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut;

- 1.1 Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini membenarkan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keseluruhan Penghakiman Y.A Hakim Bicara Tuan Asri bin Tahir bertarikh 29hb Ogos 2019 yang telah mengekalkan Perintah Interim Hak Jagaan dan Injunksi terhadap permohonan Responden untuk suatu Permohonan Interim Hak Jagaan

dan perintah Injunksi Tegahan Membawa Anak Ke Luar Negara secara Ex-Parte.

1.2 Mahkamah Yang Mulia ini membatalkan dan/atau mengenenpikan keseluruhan Penghakiman Y.A Hakim Bicara Tuan Asri bin Tahir bertarikh 29hb. Ogos 2019, yang telah mengekalkan Perintah Interim Hak Jagaan dan Injunksi terhadap permohonan Responden untuk suatu Permohonan Interim Hak Jagaan dan Perintah Injunksi Membawa Anak ke Luar Negara secara Ex-Parte.

1.3 Kos dalam tindakan ini ditanggung Responden.

1.4 Apa-apa perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh Mahkamah yang mulia ini.

FAKTA KES

2) Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 3 Mei 2013 di Kuala Lumpur dan telah dikurniakan dengan dua (2) orang cahaya mata perempuan bernama Ottilia Kusuma Diamond binti Christoph (dilahirkan pada 17 Januari 2015 dan berumur 5 tahun) dan Antonia Embun Diamond binti Christoph (dilahirkan pada 28 September 2017 dan berumur 2 tahun 5 bulan)

3) Responden telah memfailkan satu Permohonan untuk Mendapatkan Perintah Injunksi Tegahan Membawa Anak ke Luar Negara secara Ex-Parte bertarikh 19 Jun

2019 melalui Kes Permohonan No. 10100-004-0641-2019 dan pada 26 Jun 2019 Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam telah meluluskan permohonan tersebut yang mana terma perintah adalah seperti berikut;

- i. *Mahkamah memerintahkan Responden ditegah dan/atau dihalang daripada membawa anak-anak perempuan Pemohon dan Responden yang bernama Ottilia Kusuma Diamond binti Christoph (no. Mykid : 150117-14-0036) dan Antonia Embun Diamond binti Christoph (No. Mykid : 170928-14-0548) selepas ini dirujuk sebagai “ Anak-Anak Tersebut.”) ke luar negara sehingga kes hak jagaan anak kekal melalui Saman No. 10100-028-0640 Tahun 2019 selesai diputuskan dan sehingga ada perintah selainnya.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan Passport Antarabangsa Malaysia dan Austria Anak-Anak Tersebut diserahkan dan disimpan oleh Pemohon.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Pemohon diberikan hak jagaan sementara kepada Anak-Anak Tersebut sehingga kes hak jagaa kekal selesai diputuskan oleh Mahkamah.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan Responden dan/atau wakilnya atau ejennya adalah ditegah dan dilarang daripada mengganggu / mencero boh / atau membuat apa-apa tindakan dengan maksud membawa lari Anak-Anak Tersebut ke luar negara.*
- v. *Mana-mana pihak ketiga termasuk badan-badang kerajaan iaitu secara khususnya tetapi tidak terhad kepada Jabatan Imigresen Malaysia, badan-badan berkanun, peguam-peguam dan / atau agen-*

agen Responden hendaklah memberikan kerjasama dalam pelaksanaan dan pematuhan Perintah yang dikeluarkan di sini.

- vi. *Kegagalan mematuhi Perintah ini adalah melakukan suatu penghinaan kepada Mahkamah dan dengan itu boleh dikomitkan ke penjara.*
- vii. *Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak untuk melawat dan bersama Anak-Anak Tersebut tiga (3) kali seminggu iaitu pada Selasa (06.00 petang - 09.00 malam), Khamis (06.00 petang - 09.00 malam) dan Ahad (03.00 petang - 09.00 malam).*
- viii. *Mahkamah memerintahkan salinan Perintah ini beserta Notis Permohonan (ex-parte) dan Afidavit Sokongan diserahkan kepada Responden dua (2) minggu dari tarikh Perintah ini dikeluarkan.*
- ix. *Mahkamah memerintahkan bahawa Perintah Injunksi ini berkuatkuasa serta merta mulai hari ini selama 30 hari dari tarikh hari dan kes ini ditetapkan untuk pendengaran semula pada tarikh 24 Julai 2019 jam 09.00 pagi.*

4) Kes tersebut telah didengar secara inter parte dan pada 29 Ogos 2019, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan seperti berikut ;

- i. *Mahkamah memerintahkan Responden ditegah dan/atau dihalang daripada membawa anak-anak perempuan Pemohon dan Responden yang bernama Ottilia Kusuma Diamond binti Christoph (no. Mykid :*

- 150117-14-0036) dan Antonia Embun Diamond binti Christoph (No. Mykid : 170928-14-0548) selepas ini dirujuk sebagai “ Anak-Anak Tersebut.”) ke luar negara sehingga kes hak jagaan anak kekal melalui Saman No. 10100-028-0640 Tahun 2019 selesai diputuskan.*
- ii. Mahkamah memerintahkan Passport Antarabangsa Malaysia Anak-Anak Tersebut disimpan oleh Pemohon.*
 - iii. Mahkamah memerintahkan Passport Antarabangsa Austria Anak-Anak Tersebut yang dipegang oleh Responden diserahkan kepada Mahkamah sehingga hak jagaan anak kekal selesai diputuskan oleh Mahkamah.*
 - iv. Mahkamah memerintahkan Pemohon diberikan hak jagaan sementara kepada Anak-Anak Tersebut sehingga kes hak jagaan kekal selesai diputuskan oleh Mahkamah.*
 - v. Mahkamah memerintahkan Responden dan/atau wakilnya atau ejennya adalah ditegah dan dilarang daripada mengganggu / menceroboh / atau membuat apa-apa tindakan dengan maksud membawa lari Anak-Anak Tersebut ke luar negara.*
 - vi. Mana-mana pihak ketiga termasuk badan-badan kerajaan iaitu secara khususnya tetapi tidak terhad kepada Jabatan Imigresen Malaysia, badan-badan berkanun, peguam-peguam dan / atau agen-agen Responden hendaklah memberikan kerjasama dalam pelaksanaan dan pematuhan Perintah yang dikeluarkan di sini.*
 - vii. Kegagalan mematuhi Perintah ini adalah melakukan suatu penghinaan kepada Mahkamah dan dengan itu boleh dikomitkan ke penjara.*

- viii. *Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak untuk melawat dan bersama Anak-Anak Tersebut tiga (3) kali seminggu iaitu pada Selasa (06.00 petang - 09.00 malam), Khamis (06-00 petang - 09-00 malam) dan Ahad (03.00 petang - 09.00 malam).*
- ix. *Mahkamah memerintahkan bahawa Perintah Injunksi ini berkuatkuasa serta merta mulai tarikh hari ini iaitu 29hb. Ogos, 2019 sehingga kes hak jagaan anak kekal diputuskan oleh Mahkamah dan sehingga ada perintah selainnya.*

5) Pemohon telah mengemukakan empat (4) alasan di dalam permohonan semakan ini iaitu;

- 5.1 Responden telah tersalah langkah dan membelakangi prosedur Mahkamah Syariah apabila di dalam Permohonan Injunksi ke Luar Negara ini mempunyai dua (2) kausa tindakan kes yang berbeza iaitu memasukkan Permohonan Hak Jagaan Anak Sementara yang tidak wajar disekalikan di dalam Permohonan Injunksi Tegahan Membawa Anak ke Luar Negara ini.
- 5.2 Responden telah dengan sengaja memberikan fakta-fakta yang tidak benar sehingga Mahkamah Yang Mulia ini membenarkan Perintah Injunksi dan Perintah Interim ini.
- 5.3 Responden melalui Peguam Syariannya telah dengan sengaja telah membelakangi prosedur Permohonan Interim dan Injunksi sebagaimana digariskan di dalam Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016.

- 5.4 Responden melalui Peguam Syariahnya telah dengan sengaja GAGAL menyerahkan Notis Permohonan Ex-Parte, Afidavit Permohonan Ex-Parte dan perintah Ex-Parte bertarikh 26hb. Jun 2019 kepada saya selaku Responden ketika itu hanya pada 5hb. Julai 2019, iaitu melebihi tempoh tujuh (7) hari sebagaimana tempoh masa yang telah ditetapkan di dalam Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

6) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

7) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes*

tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.

- v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
- 8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
- 9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
- 10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*

11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

8) Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

9) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

10) Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan - alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan oleh kerana

permohonan semakan ini adalah terhadap perintah interim maka alasan-alasan yang dikemukakan perlulah memenuhi kehendak **Perenggan 5 dan Perenggan 7 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas.

11) Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10100-004-0641-2019 dan kami membuat dapatan seperti berikut:

11.1 Pemohon di dalam Afidavit Jawapan yang diikrarkan pada 19 Julai 2019 telah membangkitkan isu-isu berkaitan dua (2) kausa tindakan yang berbeza iaitu Permohonan Hak Jagaan Anak Sementara di dalam Permohonan Injunksi Ke Luar Negara, pernyataan fakta yang tidak benar telah diberikan oleh Responden di dalam permohonan ini, Responden dan Peguam Syariahnya telah sengaja membelakangi prosedur permohonan interim dan injunksi sebagaimana Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 dan penyampaian dokumen permohonan ini telah tidak diserahkan kepada Pemohon dalam tempoh tujuh (7) hari seperti yang telah ditetapkan di dalam Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 tersebut.

11.2 Responden di dalam Afidavit Balasan yang diikrarkan pada 31 Julai 2019 telah memberikan maklumbalas kepada isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Pemohon; antaranya mengenai dua (2) kausa tindakan yang berbeza iaitu Permohonan Injunksi yang dipohon di bawah Seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003 dan Permohonan Hak Jagaan Sementara Anak yang dipohon di bawah Seksyen 201 enakmen yang sama.

- 11.3 Responden seterusnya menafikan mengemukakan fakta yang salah di dalam permohonan ini.
- 11.4 Responden juga telah memaklumkan di dalam Affidavit Balasan bertarikh 31 Julai 2019 berkaitan pengeluaran dan penyerahan dokumen - dokumen Notis Permohonan, Affidavit Sokongan, Wakalah peguam Syarie dan perintah bagi Permohonan No. 10100-004-0641-2019 ini kepada Pemohon seperti berikut :

BIL	TARIKH	PERKARA
1	26.6.2019	Perintah diperolehi secara lisan
2	27.6.2019	Perintah bersih ditandatangani
3	28.6.2019	Peguam Syarie menyediakan surat iringan
4	29 dan 30.6.2019	Cuti umum
5	5.7.2019	Dokumen diserahkan secara kediri kepada Pemohon

Responden turut menyatakan bahawa perenggan 8 Perintah Interim Ex-Parte tersebut menyatakan penyerahan perlu dilakukan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh perintah dikeluarkan.

- 11.5 Affidavit Penyampaian bagi penyerahan dokumen-dokumen Notis Permohonan, Affidavit Sokongan, Wakalah peguam Syarie dan perintah bagi Permohonan No. 10100-004-0641-2019 telah diikrarkan pada 9 Julai 2019 bagi penyerahan secara kediri kepada Pemohon pada 5 Julai

2019 jam 9.50 oleh kakitangan firma guaman Peguam Syarie Responden.

11.6 Pemohon dan Responden masing-masing telah memfailkan Hujahan Bertulis iaitu pada 14 Ogos 2019 dan 29 Ogos 2019.

12) Kami dengan hormatnya mengatakan bahawa bagi isu-isu yang dibangkitkan oleh Pemohon di dalam permohonan semakan ini telah pun dikemukakan oleh Pemohon di dalam Afidavit Jawapan yang diikrarkan pada 19 Julai 2019 dan kedua-dua Pemohon dan Responden telah diberikan ruang dan peluang yang sewajarnya untuk membentangkan kes masing-masing di hadapan YA Hakim Bicara sebelum YA Hakim Bicara membuat penilaian dan pertimbangan terhadap kes ini semasa prosiding inter parte.

14) Kami berpendapat isu-isu yang dibangkitkan oleh Pemohon bukanlah kesilapan yang bersifat fatal terhadap kes yang disemak ini. Sehubungan dengan itu tidak ada alasan untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh;

.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....
2. **YA DATUK ~~HAJI~~ MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

.....
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor